

1527958-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... perante a autoridade policial, não evidenciando dedicação ao tráfico,

Assim decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONFISSÃO INFORMAL DE HABITUALIDADE DELITIVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527958-47.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527958-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312253/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21424632 - 26º D.P. SACOMA, 4263/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2312253 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONIEL OLIVEIRA DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

WESLEY ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e RONIEL OLIVEIRA DE JESUS, também qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta dos autos que, em 16 de novembro de 2021, por volta das 17h50, na Rua Resende Costa, n.º 155, Ipiranga, nesta Capital, WESLEY ALVES DA SILVA teria em depósito e transportaria, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 351 papétes de cocaína, com peso líquido de 114 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, RONIEL OLIVEIRA DE JESUS estaria trazendo consigo 8,2 gramas de maconha e ofereceu a droga, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, bem como portando a arma de fogo marca Taurus, numeração KIM22655, calibre .380, municiada com 13 munições íntegras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia (p. 142/144 e 160/161), os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (p. 234/248 e 251/254), que foram rejeitadas (p. 266). Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus na forma da denúncia. Na dosimetria, em relação a Wesley, manifestou-se pela fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de entorpecente, pela incidência da agravante da calamidade pública, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pela imposição do regime inicial fechado e pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já para Roniel, pleiteou a incidência da agravante da calamidade pública, a imposição do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (p. 303/330).

A Defesa do réu Roniel, por sua vez, requereu a absolvição da prática do crime previsto no artigo 33, 3º, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, não apresentando oposição à condenação na pena prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Na dosimetria, pugnou pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 4º, da Lei nº 11.343/06 e pela concessão do direito de apelar em liberdade (p. 336/364).

A Defesa do réu Wesley pleiteou a absolvição, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Reiterou pedido de revogação da prisão preventiva (p. 365/386).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal é procedente em parte.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados estão devidamente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante de p. 04/05 e 15, pelo boletim de ocorrência de p. 06/12, pelo auto de exibição e apreensão de p. 17/18, pelo laudo constatação de p. 57/60, pelo laudo pericial de p. 168/173, pelo laudo de exame químico-toxicológico de p. 297/299 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Juliano Ramalho da Silva, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela região do Heliópolis quando, ao ingressarem em uma rua, avistaram esse veículo. No momento da abordagem, perceberam que era um veículo blindado, uma Fiat Strada, e eles resistiram um pouco a desembarcar, mas concordaram após insistência. Durante a vistoria, uma porção de haxixe foi encontrada dentro da Strada e, indagados, eles alegaram que estavam consumindo o entorpecente. No bolso do Wesley foi localizada a chave de uma Saveiro, que estava logo atrás. Foram até esse veículo e, no interior, estava um cheiro muito forte de cocaína. Indagado, ele confessou que o veículo era um carro cofre, que usava para transportar droga e que havia droga no local. Pediram apoio do canil para a vistoria na Fiat Strada, pois era um veículo blindado, o que causou estranheza. Durante essa vistoria, na presença do delegado de plantão, uma pistola 380 carregada foi localizada. Aparentemente, no momento da abordagem, os réus faziam uso de haxixe, havendo, inclusive, cheiro de droga dentro da Fiat Strada. O Wesley que indicou o compartimento secreto existente na Saveiro e onde estava a droga. Sem a indicação era pouco provável sua localização. Era um compartimento no painel do veículo. Ao encontrarem a droga, ele confirmou que utilizava o veículo para fazer o transporte, não informando o nome de outros participantes. Havia mais de trezentos pinos de cocaína. A arma encontrada no interior do veículo também estava em um compartimento secreto e contaram com o auxílio de um cão farejador. Não sabe dizer se a arma tinha numeração raspada. Segundo informado, os réus trabalhavam juntos.

Eles não disseram porque pararam no local. Eles estavam parados quando efetuaram a abordagem. O fato de haver dois indivíduos dentro de um veículo blindado levantou suspeitas. Não se recorda se havia película escura no veículo. Sinalizaram com a viatura e eles só desceram após certa verbalização. Roniel não disse que portava arma de fogo, nem informou porque estava no local consumindo droga. Não se recorda se Roniel confirmou ter conhecimento da existência de outro veículo nas imediações. A forma de acionamento do compartimento secreto da Fiat Strada era similar à da Saveiro, mas não conseguiram destravar através do dispositivo do segredo e tiveram que quebrar o painel para encontrar a arma. O cão farejador que identificou a arma de fogo. Não se recorda se Roniel se manifestou sobre o veículo em que foram encontrados os entorpecentes, nem se justificou a utilização de carro blindado. Não se recorda da apreensão de dinheiro miúdo, nem dos trajes dos réus no momento da abordagem. O Wesley apontou onde estava o veículo com compartimento secreto utilizado para transportar droga. Esse veículo estava bem próximo. A vistoria na Saveiro foi realizada pela equipe e acompanhada pelo Wesley, ao lado do veículo. O Wesley não informou que o veículo seria lavado naquele momento. A localização da droga no veículo do Wesley não foi filmada.

A testemunha Daniel Nascimento de Souza, também policial militar, narrou que estavam em patrulhamento quando perceberam um veículo Fiat Strada, de cor preta, com dois ocupantes, que, com a passagem da viatura, fecharam os vidros, gerando desconfiança na equipe. Efetuaram a abordagem e, em um primeiro momento, os ocupantes resistiram em desembarcar do veículo. A ordem de desembarque, reafirmada, foi acatada após alguns minutos. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas, em vistoria veicular, encontraram determinada quantidade de entorpecente, que os réus informaram que se destinava ao consumo pessoal. Com o réu que se encontra no CDP foi localizada a chave de um veículo Volkswagen, sendo que, indagado, declarou que era de sua propriedade e que estava estacionado na mesma via, alguns veículos atrás. Efetuaram busca nesse outro veículo e um forte odor de entorpecente foi percebido. Questionado acerca do odor, o proprietário do veículo disse que se tratava de um carro forte e que o utilizava para fazer o transporte de entorpecentes. Ele ensinou como acessava o compartimento secreto que havia no carro e localizaram o entorpecente. Os dois veículos, o entorpecente e os indivíduos foram encaminhados ao distrito policial, onde, com o apoio do canil, efetuaram buscas mais minuciosas, localizando uma arma de fogo em outro compartimento secreto, com mesmo tipo de dispositivo. O proprietário do Fiat Strada negou a existência de qualquer coisa ilícita em seu veículo e esse compartimento secreto somente foi localizado em razão do auxílio prestado pelo canil. Como não tiveram acesso ao segredo deste compartimento, tiveram que danificar o veículo. O réu Wesley acompanhou a busca veicular na Saveiro e indicou o dispositivo para acesso ao compartimento. Não se recorda da quantidade de drogas. Na Fiat Strada, o réu não estava presente quando da realização das buscas, mas seu advogado acompanhou a diligência. Na Fiat Strada havia, ainda, entorpecente – maconha ou haxixe, para consumo pessoal. Os dois réus demonstraram nervosismo durante a abordagem. Roniel em nenhum momento informou que possuía a arma de fogo. Nenhum dos réus possuía registros policiais. O Roniel permaneceu a todo momento ao lado do próprio veículo e, em nenhum momento, declarou ter ciência do entorpecente encontrado no outro veículo; segundo afirmou, Wesley era seu amigo e estavam ali apenas para o consumo de drogas. Posteriormente, ambos disseram que trabalhavam com o transporte de drogas. Em cada veículo com compartimento secreto, ainda que com dispositivo similar, a forma de abrir não é a mesma. A arma apreendida possuía numeração, mas não havia informações nas bases de dados. As drogas encontradas no veículo do réu Wesley estavam em eppendorfs. O Wesley não dificultou a diligência policial e informou a localização do compartimento secreto, bem como a forma de acesso, que contava com várias etapas. A localização do entorpecente não foi filmada. O Wesley mostrou a última etapa para abertura do compartimento e acompanhou as buscas veiculares. O carro estava estacionado na frente de um lava-rápido. O Roniel confirmou que o entorpecente encontrado na Fiat Strada era de sua propriedade e que havia chamado o Wesley para juntos consumirem.

A testemunha Ednam Amaro Celestino da Silva, de interesse dos autos, confirmou ter

ciência de que Roniel possuía uma arma de fogo, mas que não a exibia, nem a empregava para efetuar ameaças; informou que ele usava carro blindado, em razão de sequestro sofrido anteriormente; e disse que não tem conhecimento do envolvimento de Roniel com o tráfico de drogas.

A testemunha Kelvin Rocha da Costa disse que o Wesley e o Roniel são seus clientes no lava-rápido. Contou ter acompanhado a abordagem e prisão dos réus, pois estava no local dos fatos. Inicialmente, esclareceu que a data e a hora exibidas nas câmeras de segurança de seu estabelecimento estão erradas, pois não conseguiu fazer o devido ajuste. Na data dos fatos, estava lavando um carro quando o Wesley chegou e disse que queria lavar o veículo. Ele deixou o carro na frente do lava-rápido e foi abordado "lá embaixo", onde também estava o Roniel, com o veículo parado próximo de uma lixeira. Posteriormente, os policiais se aproximaram e perguntaram se conhecia Roniel e Wesley, tendo dito que eram seus clientes. Eles foram até o carro do Wesley e realizaram revistas, mas não encontraram nada após aproximadamente vinte minutos. O Wesley permaneceu onde foi abordado, "lá na frente". Negou ter visto a localização de cocaína em um compartimento secreto no veículo do Wesley, conforme informado pelos policiais. O Wesley não estava ao lado do veículo. Em nenhum momento ele auxiliou os policiais na localização do comportamento secreto instalado no veículo. Esclareceu que, depois de tempo, os policiais retiraram o veículo e levaram para próximo de onde estava o Wesley. Não viu o veículo sendo revistado nesse momento, pois foi estacionado depois da viatura. Não tinha conhecimento da existência de compartimentos secretos nos veículos de Roniel e Wesley.

A testemunha Deivid Wellington da Silva Moraes disse que estava sentado na frente do lava-rápido e viu a abordagem. Relatou que os policiais chegaram, revistaram o veículo e depois desceram "lá para baixo". Posteriormente, o policial voltou, pegou o carro e o colocou atrás da viatura. Não presenciou os policiais encontrando algo. O Wesley permaneceu onde foi abordado. Viu o momento em que os réus foram abordados e eles não se aproximaram da Saveiro. Os policiais mexeram na Saveiro quando ela estava atrás da viatura, não dando para ver mais nada. O Wesley estava a aproximadamente três metros do veículo nesse momento.

O réu Roniel Oliveira de Jesus, interrogado, confirmou tanto a posse do entorpecente para o consumo pessoal como da arma de fogo encontrada no compartimento secreto instalado em seu veículo. Esclareceu que já foi sequestrado e, por isso, usa carro blindado e possuía a arma de fogo. Adquiriu o veículo já com o compartimento secreto e, realmente, não informou aos policiais que estava com a arma de fogo. Já conhecia o réu Wesley, mas não tem conhecimento de qualquer envolvimento seu com o tráfico de drogas. Não tem conhecimento de Wesley usar cocaína, nem da existência de compartimento secreto no carro dele também. Confirmou a existência do compartimento secreto no carro de Wesley, que inclusive lhe foi exibido pelos policiais. O Wesley recebia R\$ 1.500,00 por mês, além do pagamento pelo serviço de gesseiro que ele prestava por fora. Apenas às vezes o Wesley transportava dinheiro para sua mãe. A droga que estavam consumindo no local era de sua propriedade. A localização do compartimento secreto ocorreu depois que levaram o veículo para atrás da viatura e a abertura foi realizada pelo Wesley. Não estava presente quando esse compartimento foi aberto, nem viu os policiais retirando algo de ilícito de dentro. O Wesley não estava presente no momento da abertura do compartimento. Está arrependido da posse da droga para consumo pessoal.

O réu Wesley Alves da Silva negou a prática do crime imputado. O veículo Saveiro é de sua propriedade e o havia adquirido dois ou três meses antes de sua prisão. O compartimento secreto já estava instalado no veículo e sua patroa havia pedido que procurasse um carro nesse modelo para trabalhar com mais segurança, com o dinheiro guardado. Confrontado com a declaração de Roniel de que não fazia o transporte de dinheiro com frequência, afirmou que sua função principal era de fazer gesso e drywall, mas que, de vez em quando, fazia esse serviço para ela. Não recebeu ajuda de custo para adquirir o veículo com compartimento secreto. Trabalhava há mais ou menos um ano para a mãe de Roniel. Deixou o veículo no lava-rápido e acendeu seu cigarro de maconha. O Roniel chegou em seguida e também estava com um cigarro de maconha. Ele o chamou para entrar no carro e ficaram conversando. Não estava longe

de onde seu veículo estava estacionado. A chave estava em seu bolso e indicou aos policiais onde estava o veículo. Informou aos policiais que havia compartimento secreto no veículo e disse como abrir. Os policiais não conseguiram abrir o compartimento e levaram o veículo para onde estava, próximo da viatura. Nesse momento, foi chamado e mostrou onde estava o botão. Depois de abrir, o policial disse para que voltasse para onde estava, sendo interrogado por outros policiais, enquanto mexiam no veículo. A droga não estava em seu carro. Não conhecia os policiais. Não sabe como a droga apareceu. Não viu os entorpecentes em nenhum momento. Quatro policiais participaram da abordagem e, posteriormente, chegou uma nova viatura. Nunca respondeu a processo criminal. Trabalha para a mãe do Roniel e a quantia que costumava transportar variava entre R\$ 2.000,00 e R\$ 5.000,00. Pois bem.

Em que pese o esforço por parte das combativas defesas, o conjunto probatório é robusto e confere certeza da autoria e materialidade dos delitos imputados na denúncia.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, tanto em juízo como perante a autoridade policial, prestaram depoimentos uníssonos e consistentes, descrevendo a abordagem e localização de entorpecentes e uma arma de fogo nos veículos de propriedade dos réus.

Compromissados, Juliano Ramalho da Silva e Daniel Nascimento de Souza relataram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando perceberam os réus, dentro de uma Fiat Strada, de propriedade de Roniel, fechando os vidros do veículo ao notarem a presença da equipe, o que levantou suspeitas e determinou a abordagem. Contaram que, em buscas, encontraram porção de entorpecente que, segundo informado pelos réus, era destinada ao consumo pessoal. Disseram que, além do entorpecente, em posse do réu Wesley havia a chave de um outro veículo, que estava estacionado em local por ele indicado, a poucos metros dali. Esclareceram que também foram realizadas buscas nesse veículo, no qual, por sua vez, em um compartimento secreto cuja abertura foi providenciada pelo próprio Wesley, apreenderam diversas porções de cocaína. Narraram, ainda, que, indagado, Wesley teria informado que o veículo seria utilizado para o transporte de entorpecentes, sem indicar outros participantes na empreitada. Acrescentaram, no mais, que, já em solo policial, com auxílio de cão farejador, na Fiat Strada, também em um compartimento secreto, foi localizada uma arma de fogo, cuja propriedade foi confirmada por Roniel. Por fim, o policial Daniel Nascimento de Souza declarou que Roniel assumiu a propriedade do entorpecente encontrado na Fiat Strada e que havia chamado o Wesley para juntos consumirem.

Em relação ao valor probatório das palavras dos policiais, nada nos autos é capaz de infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem agentes do Estado não se mostra suficiente.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse ponto, cabe registrar que os policiais não conheciam os réus, que são primários, e nada alegado constitui indicativo de que tivessem qualquer motivo para falsamente incriminá-los.

As testemunhas arroladas pela Defesa, por sua vez, apesar de afirmarem não terem visto os entorpecentes serem encontrados pelos policiais, reconheceram que não acompanharam as buscas inteiramente. Tanto Kelvin Rocha da Costa como Deivid Wellington da Silva Moraes disseram que, após uma primeira revista realizada na frente do lava-rápido em que trabalham, local onde a Saveiro de Wesley estava

estacionada, o veículo foi levado para próximo da viatura, onde estavam os réus e não mais foi possível testemunhar a diligência. O fato de não terem sido capazes de acompanhar as buscas ao longo de toda a abordagem torna inviável que se conclua pela caracterização de eventual flagrante forjado. Ademais, é pouco crível que policiais militares em patrulhamento de rotina dispusessem de mais de 300 (trezentas) porções de cocaína para serem utilizadas na falsa incriminação de inocentes que, até então, desconheciam.

De outra banda, a negativa de autoria por parte do réu Wesley e sua tentativa de se desvincular dos entorpecentes apreendidos em compartimento secreto instalado no interior do veículo de sua propriedade, além de não contarem com qualquer respaldo probatório, não são críveis.

As imagens exibidas a partir de links indicados pela defesa (p. 184, 187 e 188) são insuficientes para comprovar que nenhum entorpecente teria sido encontrado no veículo de Wesley. Além de captarem apenas parcialmente a Saveiro do réu no momento da primeira busca realizada pelos policiais militares, ocorrida na frente do lava-rápido de propriedade da testemunha Kelvin, ao final da instrução, restou demonstrado que as porções de cocaína foram localizadas em uma segunda busca, realizada a poucos metros dali, quando o próprio réu Wesley abriu o compartimento secreto que havia em seu veículo.

Acerca da materialidade, cumpre pontuar que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, tal como no caso em tela. A quantidade, forma de acondicionamento e local onde apreendida tornam certo que a cocaína era destinada ao comércio espúrio.

No mais, o laudo de exame químico-toxicológico de p. 297/299 confirmou a materialidade delitiva, atestando a apreensão de substâncias previstas nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98.

Dessa forma, ausente qualquer verossimilhança na versão sustentada pela defesa de Wesley, bem como considerando os robustos elementos de prova provenientes, especialmente, da prisão em flagrante e dos depoimentos prestados pelos policiais militares, é forçoso concluir que Wesley mantinha em depósito e transportava depósito, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 351 papérolas de cocaína, com peso líquido de 114 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que sua condenação nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

A conclusão é no mesmo sentido em relação ao réu Roniel, que, por sua vez, confessou espontaneamente tanto a propriedade do entorpecente apreendido no veículo Fiat Strada, destinado ao consumo compartilhado com Wesley, como da arma de fogo encontrada em compartimento secreto no mencionado automóvel.

O oferecimento de droga a pessoa do próprio relacionamento para juntos consumirem caracteriza o delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, tipo especial em relação ao constante do artigo 28 do mesmo diploma legal, não havendo, portanto, o que se falar em desclassificação diante da comprovada presença do elemento específico do tipo, qual seja, o oferecimento para consumo compartilhado. A prova oral, inclusive decorrente do interrogatório de Roniel, é nesse sentido.

Já quanto à arma de fogo apreendida, o trauma causado por sequestro anteriormente sofrido não autoriza o porte pela vítima, nem a ausência de seu emprego para ameaçar ou constranger pessoas constitui privilégio a ser valorado em favor do réu. A conduta encontra previsão no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e sua ilicitude decorre do mero porte de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, no caso uma pistola da marca Taurus, numeração KIM22655, calibre .380, cuja potencialidade lesiva foi atestada pelo laudo de p. 289/294.

Assim, não havendo dúvidas da autoria e materialidade dos delitos previstos no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, a condenação do réu Roniel também é medida de rigor.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que nada há de desfavorável aos réus, razão pela qual fixo as penas base em: i) 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o réu Wesley; e ii) 06 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, além de

advertência sobre os efeitos das drogas, pelo delito previsto no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 para o réu Roniel.

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a confissão espontânea por parte do réu Roniel, mas, observado o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho as penas nos patamares mínimos.

Neste ponto, cumpre registrar que nada nos autos indica que os réus tenham se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática dos crimes, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Quatro indivíduos se aproximaram da vítima a bordo de um veículo, sendo que três deles desembarcaram e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta do ofendido. Menos de duas horas após a prática criminosa, os réus foram localizados na condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa, sendo reconhecidos pela vítima e detidos em poder do instrumento bélico e do aparelho celular subtraído. A motocicleta foi encontrada estacionada nas proximidades. Autoria e materialidade comprovadas. Prova oral satisfatória à confirmação dos fatos. No entanto, conquanto o concurso de agentes esteja bem delineado pelo acervo probatório, tratando-se da inequívoca participação de quatro indivíduos, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída, porquanto, consoante laudo pericial de fls. 179/182, a arma era absolutamente inapta ao disparo ("devido à ausência do pino percutor"). Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento." (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor. PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - REGIME PRISIONAL FECHADO - PEDIDO DE ABRANDAMENTO - REU REINCIDENTE e COM MAUS ANTECEDENTES - REGIME FECHADO IMPRESCINDÍVEL - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO." (TJSP; Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Em relação ao réu Wesley, em razão de sua primariedade (p. 72), da comprovação de trabalho lícito (p. 197) e não constando dos autos prova de que integre organização criminosa ou se dedique, habitualmente, a práticas criminosas, entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2. Em seu caso, a natureza da substância apreendida - cocaína - droga de alto poder vulnerante, revela maior desvalor da conduta e justifica a redução do benefício.

Registro que as declarações prestadas pelos policiais de que Wesley teria confessado realizar o recorrente transporte de entorpecentes e que seu veículo seria um carro cofre não foi confirmada pelo réu nem mesmo perante a autoridade policial, não evidenciando dedicação ao tráfico,

Assim decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONFISSÃO INFORMAL DE HABITUALIDADE DELITIVA SUPOSTAMENTE FEITA AOS POLICIAIS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS À

ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO. ART. 33, § 2.º, ALÍNEA C, E § 3.º, C.C. O ART. 59, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a orientação fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Acusados com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Outrossim, a mera referência à suposta confissão informal que os Réus teriam feito às autoridades policiais no momento das prisões em flagrante de integrarem o tráfico de drogas da Comunidade Nova Grécia, não evidencia, por si só, a dedicação dos Acusados ao tráfico de drogas, especialmente porque tal afirmação sequer foi confirmada em juízo. 3. Diante disso, perfeitamente aplicável a causa de diminuição no grau máximo, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Ordem de habeas corpus concedida. (HC 662.258/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)

Ademais, referido privilégio tem aplicação restrita ao delito previsto no artigo 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06, conforme dispõe expressamente a norma ("Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"), sendo inviável o acolhimento do pedido formulado pela defesa de Roniel.

Em consequência, inexistindo causa de aumento a ser valorada, fixo as penas definitivas em: i) 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa para o réu Wesley; e ii) 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa, além de advertência sobre os efeitos das drogas para o réu Roniel, em relação ao qual, por força da prática de dois crimes a partir de condutas distintas, incide a regra prevista no artigo 69 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada aos réus, imponho, para ambos, o regime inicial aberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade, em atenção ao disposto na súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade fixadas para cada um dos réus por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo período fixado para pena privativa de liberdade, bem como no pagamento de prestação pecuniária a entidade pública oportunamente indicada, que fixo em um salário mínimo, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente fixada. Nesse ponto, vale registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, Rel. Min. Carmen Lúcia, concluiu que o tráfico privilegiado não deve ser equiparado a crime de natureza hedionda, sendo cabível, excepcionalmente, a fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

A) CONDENO o réu WESLEY ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade na forma acima especificada; e

B) CONDENO o réu RONIEL OLIVEIRA DE JESUS, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa, além de advertência sobre os efeitos das drogas, em regime inicial aberto e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº

10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade na forma acima especificada. Em razão do regime inicial fixado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do réu Wesley. Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos (salvo pequena amostra, que poderá servir como contraprova). Em relação ao veículo Saveiro apreendido (p. 17/18), em que pese a existência de indícios de que era utilizado por Wesley, ao que parece, o réu não consta como seu proprietário, razão pela qual deixo de decretar o perdimento. Encaminhem-se a arma de fogo e as munições ao Comando do Exército, para os fins previstos no artigo 25 da Lei nº 10.826/03. Com o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais. Custas ex lege. P.R.I.C.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA